

1501100-95.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... R\$ 60,00 no bolso na data dos fatos e estava indo ao ponto do tráfico para comprar três "buchas" de maconha, já que é usuário há alguns anos; quando estava se dirigindo ao ponto do tráfico, parou em uma barraca de "espetinho" que fica próxima ao local, onde comprou um espetinho no valor de R\$ 2,00, tendo sobrado, portanto, R\$ 58,00, então desceu até o ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501100-95.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-95.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS DOS SANTOS PROSPERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

DENIS DOS SANTOS PROSPERO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 10 de outubro de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, por volta das 17h35min, na Rua Riacho Doce, 100, Chácara Maringá, nesta cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 03 porções de maconha, 40 de cocaína e 07 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o réu trazia consigo, dentro de uma sacola, as drogas acima indicadas, na mencionada via pública - que é notória por ser ponto de narcotráfico. Com efeito, logo que avistou policiais que patrulhavam a região, saiu correndo e arremessou a sacola que continha os entorpecentes para o interior de uma casa. Tal atitude chamou a atenção dos agentes da lei, que foram ao seu encalço e conseguiram detê-lo, quando ele tentava pular o portão da mesma residência para onde havia arremessado a sacola. Posteriormente, os milicianos localizaram a sacola e constaram que nela, além das drogas, havia a quantia de R\$ 28,00, em notas trocadas.

É certo que, na ocasião, o réu estava agressivo e populares tentavam resguardá-lo da ação dos policiais. Por isso, foi necessário o uso de força moderada, inclusive com o apoio de outra equipe policial, para contê-lo e detê-lo.

Na delegacia, DENIS optou por ficar calado.

Em laudo de constatação preliminar e exames químico-toxicológicos, verificou-se que as substâncias apreendidas são entorpecentes constantes da lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

É certo que o crime em análise foi praticado na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20.

O flagrante foi convertido em preventiva às fls. 59/63.

O réu foi notificado (fls. 153), e apresentou defesa prévia (fls. 162/163), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 165/167).

O réu foi citado (fls. 191).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 192/193).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 194/198).

A defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que não há nenhum elemento sólido de convicção que autorize a condenação; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela fixação da pena no mínimo legal (fls. 202/205).

É o relatório.

Passo a decidir.

Primeiramente, quanto à insurgência da defesa, em audiência (fls. 192/193), quanto ao disposto no art. 212 do CPP, anoto que se trata de mero erro de interpretação. A nova redação dada ao art. 212 do CPP não proibiu que o juízo inicie as perguntas, mas tão somente excluiu o sistema anterior, no qual as inquirições da vítima e das testemunhas haviam de ser, sempre, intermediadas pelo juiz, para implantar novo sistema, por meio do qual as perguntas podem ser feitas pelas partes, diretamente. Tal sistema de intermediação foi mantido no interrogatório, no rito do júri, entre outros.

E no caso dos autos, como em todos os processos criminais em trâmite na Vara, este juízo sempre permitiu que o MP e os advogados perguntassem diretamente às partes. Sobre o assunto, brilhante manifestação do STF ocorreu em data recente:

EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2018; HC 138.687 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01/03/2017; HC 122.381 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 09/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 03/09/2014; HC 121.684 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/05/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/04/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/04/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/08/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/08/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/04/2014; HC 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/09/2013). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem

flagrante constrangimento ilegal. 4. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). No mesmo sentido: HC 172.697 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013 e RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2012. 5. A defesa do paciente trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes desta CORTE: HC 130.433/SP, SP 18/04/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/08/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/04/2014; HC 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/09/2013). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). No mesmo sentido: HC 172.697 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013 e RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2012. 5. A defesa do paciente trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes desta CORTE: HC 130.433/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2018; HC 132.149 AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/06/2017; RHC 129.663 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; RE 971.305 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; HC 120.121 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2016; HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/08/2016 e AP 481 EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014. 6. Habeas corpus não conhecido. (PRIMEIRA TURMA DO STF. HABEAS CORPUS 175.048 - RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO - REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 28/04/2020).

No corpo do referido acórdão, o Excelentíssimo Ministro consigna:

“TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – ORDEM. Cabe ao juiz, na audiência de instrução e julgamento, observar o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal, assegurando que a inquirição de testemunhas seja feita pelas partes, podendo veicular perguntas caso necessário esclarecimento – inteligência do artigo 212 do Código de Processo Penal. Cumpre reiterar a óptica veiculada, em 29 de novembro de

2019, ao implementar a medida acauteladora, considerada a inobservância ao artigo 212 do Código de Processo Penal: [...] Quanto à ordem de realização de perguntas às testemunhas, na audiência do dia 28 de novembro de 2018, formalizou-se requerimento buscando a observância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal. O Juízo não acolheu o pedido, sob os seguintes argumentos: [...] Indefiro o pedido, pois a nova redação do artigo 212 do CPP, não impede que o juiz inicie inquirindo as testemunhas. Nesse sentido o entendimento de Nucci que entende que a nova redação do art. 212 do CPP não alterou o sistema inicial de inquirição. Afirma que "quem começa a ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes, dizia-se que 'as perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha', agora se diz que 'as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...)'. Argumenta que "nenhuma modificação foi trazida no tradicional método de inquirição, iniciado sempre pelo magistrado" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., p. 480). Além do que, a suposta falta de observância da nova sistemática 212 do CPP não acarreta nulidade absoluta. Pelo que ressaí da inteligência do artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A defesa não afirmou qual prejuízo sofreria o réu, pois evidentemente inexistente. Ainda, reperguntando a parte ao final, após as reperguntas de quem arrolou o depoente, preserva-se o contraditório, evitando-se qualquer surpresa com a indagação final pelo juízo. [...]. O critério ficou à margem do versado no artigo 212 do Código de Processo Penal: "As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida". O parágrafo único do artigo dispõe que, "sobre os pontos não esclarecidos, o Juiz poderá complementar a inquirição". A ordem jurídica apenas prevê a possibilidade de o próprio Juiz veicular perguntas se verificados, ante o questionamento das partes, pontos não esclarecidos. Precedente: habeas corpus nº 111.815, Primeira Turma, redator do acórdão o ministro Luiz Fux. [...]

E prossegue o E. Relator: Com relação à matéria de fundo deste Habeas Corpus, convém destacar que a alteração ocorrida no art. 212, do Código de Processo Penal, por força da Lei n. 11.609/08, teve por escopo facilitar a coleta de provas, substituindo, no âmbito do processo penal, o modelo de cross examination pelo direct examination. Até então vigorava o modelo presidencialista, por meio do qual as inquirições da vítima e das testemunhas haviam de ser, sempre, intermediadas pelo Juiz de Direito (eram feitas, sem a mínima racionalidade, reperguntas das perguntas realizadas pelas partes). Inclusive, na época em que fui Promotor de Justiça pude notar, diversas vezes, como esse sistema era inacreditável: você fazia a pergunta para o juiz, o juiz fazia a pergunta para a parte, a parte respondia para o juiz, ele respondia. Tudo isso, insisto, sem a mínima racionalidade! Embora esse modelo de reperguntas, sob o meu ponto de vista, fosse inadequado, isso não significa que tal sistema era incompatível com a Constituição Federal, em razão do modelo acusatório (art. 129, I), tampouco tinha o condão de gerar "parcialidade" do Magistrado na condução da audiência. O mencionado diploma reformador trouxe, apenas, uma mudança procedimental quanto à oitiva de vítimas ou testemunhas, buscando evitar a velha repetição mecânica que o Magistrado fazia às perguntas formuladas pela acusação e pela defesa, haja vista que muitas dessas perguntas já eram facilmente compreendidas por quem as ouvia. Ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, a referida mudança não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado possa fazer inquirição prévia. Não vedou que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir. Qual foi a grande alteração do 212, do Código de Processo Penal? Evitar algo extremamente arcaico em nosso Direito: todas as perguntas, sejam da acusação, sejam da defesa, serem feitas pelo Magistrado. Basta a leitura dos referidos dispositivos para compreender de forma clara o que está sendo dito: Redação antiga Art. 212. As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já respondida. Redação atual Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes

diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008); Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008). Deste modo, as perguntas devem ser feitas diretamente à testemunha, "não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida " (isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória, nada obstante a sobredita mudança procedimental). Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquiria as testemunhas.

Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: Porém, há de se ressaltar o seguinte: foi alterado, apenas, o sistema de inquirição feito pelas partes. Nada mais. O juiz, como presidente da instrução e destinatário da prova, continua a abrir o depoimento, formulando, como sempre fez, as suas perguntas às testemunhas de acusação, de defesa ou do juízo. Somente após esgotar o seu esclarecimento passa a palavra às partes para que, diretamente, reperguntem. Primeiramente, a acusação repergunta às suas testemunhas, para, na sequência fazer o mesmo a defesa. Em segunda fase, a defesa repergunta diretamente às suas testemunhas para, depois, fazer o mesmo a acusação (Manual de processo penal e execução penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 473). E completa o referido doutrinador: Há entendimento no sentido de que a nova redação do art. 212 do CPP alterou, inclusive, a ordem de inquirição, obrigando o juiz a dar a palavra, inicialmente, às partes, para que produzam suas perguntas diretamente às testemunhas (primeiro, o órgão acusatório às testemunhas por ele arroladas; depois, a defesa, às suas testemunhas). Ao final, se tiver interesse, o juiz poderá fazer perguntas para o seu esclarecimento pessoal. Com isso não concordamos. A pretensão de transformar o processo penal brasileiro no sistema americano ou partir para o acusatório puro é frágil e inadequada. Não se terá um novo sistema processual penal pela modificação de um único artigo do Código de Processo Penal. Olvida-se, afinal, poder o magistrado produzir tantas provas quantas ele desejar, de ofício, sem que nenhuma das partes manifeste interesse. Olvida-se que, no cenário das testemunhas, o juiz do feito pode arrolar quem bem quiser, sem prestar contas às partes. ENFIM, O JULGADOR, MESMO APÓS A REFORMA DE 2008, CONTINUA O PRESIDENTE DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL QUE SE DIGA SER O ÚLTIMO A PERGUNTAR. AS PARTES NÃO PASSAM A TER O DOMÍNIO DA INSTRUÇÃO OU DA AUDIÊNCIA, APENAS REPERGUNTAM, ISTO É, DIRIGEM INDAGAÇÕES ÀS TESTEMUNHAS, QUANDO NÃO HOUVER PERGUNTA FORMULADA PELO MAGISTRADO. (Manual de processo penal e execução penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 474).

Igualmente, LUÍS FLÁVIO GOMES, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO: A leitura apressada deste dispositivo legal pode passar a impressão de que as partes devem, inicialmente, formular as perguntas para que, somente a partir daí, possa intervir o juiz, a fim de complementar a inquirição. Não parece ser exatamente assim. Basta ver, por exemplo, a redação do art. 188 do CPP, a determinar que, no interrogatório, de início as perguntas são formuladas pelo juiz que, depois, consultará às partes se há algo a ser esclarecido. E mesmo a atual redação do art. 473 do CPP, que, no plenário do júri, determina a primazia do juiz de colher o depoimento da vítima e das testemunhas, para depois facultar às partes a formulação de perguntas. Afrontaria mesmo nossa tradição conceder-se, desde logo, a palavra às partes, para que o juiz, por último, pudesse perguntar à testemunha. Melhor que fiquemos com a fórmula tradicional, arraigada na "praxis" forense, pela qual o juiz dá início às suas indagações para, depois, facultar às partes a possibilidade de, também, inquirirem a testemunha, desta feita diretamente, sem a necessidade de passar, antes pelo filtro judicial. (Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 302).

Assim, a despeito da alteração na redação do art. 212, do Código de Processo Penal, ter objetivado a facilitação na coleta de provas e gerado certa controvérsia a respeito de quem deve iniciar a colheita dos depoimentos, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que eventual violação à ordem de inquirição de testemunhas ou mesmo a formulação das perguntas pelo Magistrado e não diretamente

pelas partes, caracterizaria, no máximo, nulidade relativa, passível, portanto, de comprovação de prejuízo pelas partes, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do Código de Processo Penal). (...) A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a inversão na ordem dos inquiridores das testemunhas, prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal, pode gerar no máximo nulidade relativa: [...] Portanto, cumpria ao ilustre impetrante demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo, o que não cuidou de fazer, notadamente em face da norma do artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É a consagração do princípio pas de nullité sans grief. Segundo este entendimento: "a demonstração de prejuízo, a teor do art. do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta".

Assim, a interpretação do quanto disposto no art. 212, do CPP foi feita de forma equivocada pela defesa e não houve qualquer prejuízo a qualquer das partes.

Pontuada tal questão, ao mérito.

Neste, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 32/35), no auto de exibição/apreensão (fls. 30), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 27/28), nas fotografias (fls. 19/25), nos laudos toxicológicos (fls. 97/99 e 100/102), no laudo pericial (fls. 141/143) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, optou por permanecer em silêncio (fls. 05).

Em juízo, interrogado, negou os fatos. Disse que estava com R\$ 60,00 no bolso na data dos fatos e estava indo ao ponto do tráfico para comprar três "buchas" de maconha, já que é usuário há alguns anos; quando estava se dirigindo ao ponto do tráfico, parou em uma barraca de "espetinho" que fica próxima ao local, onde comprou um espetinho no valor de R\$ 2,00, tendo sobrado, portanto, R\$ 58,00, então desceu até o ponto de tráfico para pegar suas porções de maconha, tendo comprado três porções, no valor de R\$ 10,00 cada uma, sobrando, após isso, R\$ 28,00; quando os meninos que estavam "trabalhando" no local lhe entregaram a droga e o troco, os policiais, em motocicletas, adentraram a rua, ocasião em que os meninos correram, sendo que um policial os perseguiu, enquanto o outro ficou consigo; após três ou quatro minutos, um policial veio, com a sacola, e disse que não conseguiu pegar os meninos, perguntando-lhe, ainda, se tinha passagem, ao que respondeu que tinha, então o policial falou que a droga era sua, razão pela qual resistiu à prisão, e os moradores que estavam no local viram que estava sendo injustiçado e tentaram ajudá-lo; os policiais pediram reforço, sendo que não quis se manifestar naquele momento, apenas em juízo; questionado se nega, disse que sim; trabalhava no lava-rápido e ganhava R\$ 60,00 por dia; usava maconha todos os dias, cerca de três porções por dia; questionado se gastava R\$ 30,00 com droga por dia, disse que "isso"; questionado se gastava R\$ 900,00 por mês só com drogas, disse que é usuário há alguns anos, então sempre fuma maconha; estudou até a oitava série; já foi processado por tráfico de drogas uma vez, e teve que prestar serviço comunitário; questionado se já foi processado na Vara da Infância, disse que não; não havia como jogar a droga em uma casa e tentar pular para dentro do mesmo imóvel, sendo que os policiais falaram que o portão estava aberto, o que não tem lógica; pede que seja analisado com carinho, pois está sendo acusado injustamente, já que foi até o local apenas para pegar drogas para seu uso, sendo que estava trabalhando no lava-rápido, na região da Av. Lucas Lima; seu filho está prestes a nascer, no dia três ou quatro de abril, e sua mulher precisa muito da sua ajuda; às reperguntas, questionado se tem conhecimento que seu genro é apontado como líder de uma organização criminosa, disse que não, sendo que na data dos fatos ele não estava no local; questionado quantas pessoas havia na rua, disse que quando chegou, havia apenas alguns moradores conversando mas, após a abordagens, aumentou a quantidade de pessoas presentes, e não conseguiu ver quantas eram; questionado se havia algum comércio por perto, ou pessoas na rua, além dos indivíduos que estavam traficando, disse que tinha um barzinho na esquina, bem próximo ao ponto de tráfico, bem como a barraca de "espetinhos"; questionado se era comum que esses estabelecimentos comerciais

ficassem abertos naquela rua, e se podem ser localizados atualmente, disse que sim (fls. 192/193).

A testemunha Patrick da Silva Xavier, policial militar, ouvida às fls. 192/193, disse que realizava patrulhamento, em equipe de motocicleta, na região dos predinhos do Riacho Doce, no Caetetuba, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que perdura por vinte e quatro horas, quando adentrou uma viela local, onde o réu, ao visualizar a presença da equipe, empreendeu fuga, sendo alcançado e contido quando tentou pular o portão de uma residência; na ocasião, o réu foi visto arremessando uma sacola em um quintal, e estava bastante alterado, tendo tentado investir contra as equipes, sendo contido com uso de força moderada, por meio de técnicas de imobilização; o réu é genro de um dos líderes criminosos de Atibaia, razão pela qual o local se tornou hostil, sendo solicitado apoio a equipes com viaturas de quatro rodas, tendo DENIS sido contido e colocado dentro da viatura; no quintal, foi encontrada a sacola arremessada pelo réu, contendo quarenta papелotes de cocaína, três "buchas" de maconha e sete pedras de crack, sendo que, no bolso de DENIS, havia R\$ 28,00; diante dos fatos, o réu foi conduzido à Delegacia de plantão; questionado o que o réu disse na ocasião, disse que no momento, ele estava muito alterado, e não falou nada; já conhecia o réu de outras abordagens, mas não havia encontrado nada de ilícito com ele; às repêrguntas da defesa, questionado de onde veio a informação de que o réu seria genro de um líder de uma organização criminosa em Atibaia, disse que o próprio líder de facção estava no local; questionado se o líder foi conduzido junto, disse que não tinha nada de ilícito com ele, que estava inflamando os moradores para que o réu fosse solto; questionado se o líder já estava na rua no momento da abordagem, ou ele saiu após a chegada da equipe, disse que saiu após a contenção do réu; questionado sobre ter dito que, no local, funciona um ponto do tráfico de drogas, por vinte e quatro horas, e se sabe se há alguma investigação em curso, da Polícia Militar ou da Polícia Civil, que aponte isso, disse que isso não cabe aos policiais militares, e não sabe sobre o andamento de investigações, mas é de conhecimento que o tráfico no local ocorre vinte e quatro horas por dia; questionado se havia usuários no local, disse que não, estava apenas o réu; questionado se o terreno em que foram lançados os entorpecentes era uma residência, disse que era o quintal de uma residência; questionado se o proprietário dessa residência estava no local, disse que não, não tinha ninguém; questionado como entraram na residência, disse que o portão estava aberto; o réu ia pular um portão aberto, feito de madeira e chapa; o réu foi preso enquanto escalava o portão; questionado se há uma residência no local, e se há moradores, disse que tem uma residência no interior do quintal; não saiu ninguém do local, sendo que o portão estava aberto, e não houve necessidade de verificar se havia alguém; questionado se não houve pedido de autorização para entrar no local, e adentraram o terreno em razão do flagrante, disse que sim, o portão estava aberto, e a sacola foi visualizada no quintal; questionado se o portão estava aberto, por que o réu tentou pular o portão, disse que não sabe; ele escalou o portão, ocasião em que o pegou; o réu se pendurou para transpor o portão, sendo que acha que ele não viu, em razão do desespero decorrente da fuga; questionado se o quintal foi todo vasculhado, ou se retornou após ter encontrado a sacola com os entorpecentes, disse que olhou a sacola, bem como as imediações do local; questionado se chegou a olhar o restante do terreno, disse que não; não havia necessidade, pois viu a sacola que o réu arremessou, então não tinha porque entrar na casa de outra pessoa; questionado se foi quem viu o réu arremessando a sacola, ou foi seu parceiro, disse que ambos viram, mas foi quem agarrou o réu; questionado se não foi colhido o depoimento do réu no momento da abordagem, disse que não, ele não quis falar; questionado o que foi localizado com o réu no momento da abordagem, disse que com ele foi localizada a quantia de R\$ 28,00, sendo que as drogas estavam na sacola; questionado se todas as drogas, sendo a maconha, a cocaína e o crack, estavam na sacola, disse que sim; questionado se nenhum volume maior de dinheiro foi localizado, disse exatamente; questionado se foi quem segurou e revistou o réu, disse que retirou o réu do portão, e seu parceiro ajudou a contê-lo; com a chegada das equipes, realizaram a revista, uma vez que não poderiam revistá-lo com todos os populares em volta; questionado se não havia ninguém na rua naquele momento, apenas

o réu, e se ninguém mais saiu correndo disse que na hora, apenas ele; questionado quem foi o policial que realizou a revista pessoal do réu, disse que não se recorda; não foi quem revistou, então provavelmente foi seu parceiro; apenas retirou o réu do portão; questionado se estava com a sacola, disse "isso"; questionado se abriu a sacola e as porções de maconha estavam dentro, disse que quando a sacola caiu ao ser arremessada, as drogas se espalharam ao solo, sendo que recolheu a droga; questionado se recolheu as porções de maconha junto com as porções de cocaína, informado que o réu disse que a maconha estava no bolso dele, e questionado se a maconha não estava no bolso dele, disse que não, estava tudo na sacola.

A testemunha Filipi Barbosa Bucciarelli, policial militar, ouvida às fls. 192/193, disse que estava em patrulhamento, juntamente com seu parceiro, em equipe de moto-patrulhamento, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes quando, ao adentrar a Rua do Riacho Doce, se depararam com um indivíduo, que ao notar a presença da equipe, empreendeu fuga, tentando pular um muro alguns metros à frente, ocasião em que dispensou uma sacola em um terreno; conseguiu deter o réu, juntamente com seu parceiro, fazendo uso moderado de força para contê-lo, ocasião em que o genro do réu tentou inflamar os populares para que DENIS fosse liberado, tendo se identificado como um dos líderes de uma facção de Atibaia; com a chegada das equipes de apoio, conseguiram conter o réu e, antes de chegarem ao portão, perceberam que havia entorpecentes espalhados, sendo que quando conseguiram entrar, constataram que havia quarenta papelotes de cocaína, três "buchas" de maconha, e sete porções de crack; revistou o réu, com quem achou a quantia de R\$ 28,00; o réu, indagado, não quis se manifestar, tendo sido conduzido à Delegacia; não conhecia o réu de outras abordagens; às reperguntas da defesa, questionado de onde veio a informação de que o réu seria genro de um líder de uma facção criminosa, disse que o genro do réu se identificou dessa forma, sendo que, posteriormente, o próprio réu também falou isso; questionado se, no curso da abordagem, isso foi dito à equipe, mas apenas o réu foi conduzido à Delegacia, disse que após a chegada na Delegacia, realizam o E.C.D, sendo que é o IML quem leva o preso à Santa Casa, para constatar eventual lesão, retornando, em seguida, para a Delegacia; questionado se foi localizado um transeunte com entorpecentes e, na ocasião, comparece uma pessoa que se identifica como líder de uma facção criminosa, para resgatar o preso, e não é conduzida à Delegacia, disse que é complicado conduzir à Delegacia uma pessoa que se identifica como líder de uma facção, pois teria que provar, portanto, estaria praticando crime de abuso de autoridade; no momento da ocorrência, havia o flagrante, sendo que não realizaram a abordagem também em razão da grande quantidade de pessoas no local; o foco era a segurança da equipe e do abordado; todos poderiam se identificar como líderes de facção criminosa, sendo que não poderia levá-los para a Delegacia, pois estaria praticando crime de abuso de autoridade, portanto, seria preso; questionado se interpreta como crime de abuso de autoridade prender uma pessoa que se identificou como líder de uma facção criminosa a um policial, disse que não tem como provar, na Delegacia, que a pessoa é do PCC, se ela disser que não falou nada; não trabalha com câmera, então não tem como provar isso, sendo que, na ocasião da abordagem, em razão dos ânimos exaltados, não havia como fazer isso; questionado quantas pessoas havia na rua, disse que no momento da abordagem do réu, somente ele, mas posteriormente não havia como contar; questionado se apareceu praticamente uma multidão de pessoas na rua após a chegada da equipe, disse que após terem abordado o réu, sim; questionado se, quando virou a esquina, apenas o réu estava no ponto de tráfico, e se não tinha ninguém na rua, disse que não, somente ele; questionado se não tem nenhum bar por perto, disse que não; chegou a visualizar o arremesso da sacola com entorpecentes, assim como seu parceiro; questionado onde foi localizada a droga, disse que não foi dentro de uma residência, e sim no quintal de uma residência, bem próximo ao portão, sendo que o réu não teve força para jogar; o réu tentou pular o muro, no entanto, o portão estava aberto; questionado se o portão estava escancarado, disse que não, era um portão de aço galvanizado, fechado; não sabe se o réu achou que estava fechado, pois ele tentou pular o muro; questionado quem entrou na residência, disse que não foi na residência, e sim no quintal; questionado quem entrou no quintal, disse que

foi seu parceiro, sendo que fez a segurança dele; questionado quem autorizou a entrada, disse que não tinha ninguém na residência, nem no quintal; questionado se entraram porque o portão estava aberto, disse que sim, pois as drogas estavam esparramadas, era nítido que aparentavam ser cocaína, maconha e crack; questionado se foi quem fez a revista pessoal do réu, disse que sim; questionado se não havia maconha no bolso do réu, e sim no chão do quintal, disse que estava dentro da sacola, juntamente com os outros entorpecentes, porém, quando ele arremessou a sacola para o quintal, algumas porções ficaram espalhadas; a única coisa que estava dentro do bolso do réu era a quantia de R\$ 28,00; questionado se, pela sua experiência, R\$ 28,00 corresponde à venda de muitos entorpecentes, disse que pela sua experiência, tanto em Atibaia, quanto em São Paulo, quando o turno está se iniciando, o que acredita que era o caso do réu, não há necessidade de ter muito, sendo que achou que tinha muito dinheiro com o réu; questionado se R\$ 28,00 seria muito dinheiro, disse que é, em razão da quantidade de drogas que estava com ele, sendo que normalmente os traficantes não permanecem com muitos entorpecentes nos pontos, então, o pouco dinheiro que estava ali, o faz acreditar que o réu estava iniciando os trabalhos; questionado se sabe onde fica a residência do réu, disse que não, sendo que não o conhecia; questionado se as pessoas que se identificaram como líderes de facção residiam nas proximidades, disse que sim pois, como patrulha aquela região, acaba visualizando alguns indivíduos, então acredita que alguns deles moram lá; questionado se consegue apontar um número aproximado de pessoas que havia no local, disse que não.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em fase policial, optou por permanecer em silêncio, sendo que em juízo, negou os fatos, alegando, em síntese, que a droga não era sua, e sim dos traficantes, que fugiram com a chegada da polícia, sendo que foi até o local para comprar três "buchas" de maconha para consumo próprio.

A versão dada pelo réu não merece qualquer credibilidade, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos, tendo sido infirmada pelas demais provas produzidas. Senão, vejamos.

Os policiais narraram, em síntese, que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando adentraram uma viela local, onde estava somente o réu que, ao visualizar a presença da equipe, empreendeu fuga, arremessando uma sacola em um quintal de uma residência, sendo capturado enquanto tentava pular para dentro do quintal da referida residência. Disseram, também, que a sacola continha três "buchas" de maconha, quarenta papéletes de cocaína e sete pedras de crack, tendo sido encontrada, com o réu, a quantia de R\$ 28,00. Por fim, narraram que DENIS estava muito exaltado no momento da abordagem, ocasião em que compareceu ao local um indivíduo que se identificou como líder de uma organização criminosa de Atibaia e genro do réu, que inflamou os populares para que o réu fosse liberado.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexistente qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou

suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na gratuita acusação do réu.

Assim, verifica-se que os relatos dos policiais se mostraram firmes e coerentes, tendo sido narrado, com riqueza de detalhes, como se deu a abordagem, ocasião em que o réu tentou se evadir ao perceber a presença dos agentes da lei, dispensando, durante a fuga, uma sacola contendo considerável quantidade de entorpecentes, embalados individualmente, prontos para a venda, o que se confirmou pelas fotografias e pelos laudos juntados, não havendo que se falar, portanto, em ausência ou insuficiência de provas, ao contrário do que alegou a defesa, em seus memoriais, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é reincidente específico, o que será analisado em fase própria.

Sobre a culpabilidade, nada a considerar. Quanto à sua conduta social, lamentável. Não obstante já ter respondido por tráfico de drogas, segue na mesma atividade ilícita, demonstrando que faz do crime seu meio de vida, tendo sido flagrado durante a prática do crime dos autos enquanto ainda cumpria pena por outro crime idêntico, restando claro seu desapeço pelas leis e pelo convívio em sociedade, merecendo, portanto, maior reprimenda. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas.

Quanto à natureza e quantidade do produto, verifica-se que o réu trazia consigo 03 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 40 porções de cocaína e 07 pedras de crack, todas prontas para a venda, além de R\$ 28,00, em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06).

Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Não bastasse, ainda foi apreendida uma considerável quantidade de porções de cocaína, além de maconha, entorpecentes ilegalmente inseridos na sociedade, causadores de verdadeiras tragédias pessoais, familiares e sociais. A quantidade total de entorpecentes apreendidos seria capaz de atender um grande número de consumidores, o que não se pode admitir.

Assim, diante da conduta social do réu e da quantidade e variedade, além do grau de nocividade e poder viciante das drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do art. 61, II, j, do CP, já que os fatos foram praticados durante estado de calamidade, decretado em razão da pandemia Covid-19, bem como a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 37/38 (1500164-07.2020 – tráfico), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de aumento de pena.

Afasto a incidência do benefício do parágrafo 4º, porque o réu é reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais, dedicando-se, como dito, às atividades criminosas.

Incabível, também, a substituição do art. 44, bem como a suspensão do art. 77, ambos do Código Penal, porque, repito, se trata de réu reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão dos benefícios.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as